学校代码 10530　　学　　号 201510070816
分 类 号 D922.22　　密　　级 公开

湘潭大学

硕士学位论文

跨国云计算服务营业利润课税权分配问题研究

学位申请人 冯忠芳
指导教师 王霞 教授
学院名称 法学院
学科专业 法律硕士（非法学）
研究方向 知识产权

二零一八 年 五 月 二十七 日

Research on the allocation of taxation right of business profits of transnational cloud computing services

Candidate Feng Zhongfang

Supervisor Pro.Wang Xia

College Faculty of Law

Program Juris master

Specialization Intellectual property right

Degree Master of law

University Xiangtang University

Date May 27, 2018

湘潭大学

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名：冯忠芳　　日期：2018年 6 月 6 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权湘潭大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

涉密论文按学校规定处理。

作者签名：冯忠芳　　日期：2018年 6 月 6 日

导师签名：　　日期：2018年 6 月 6 日

摘要

在技术驱动经济发展的今天，尤其是云计算的兴起，一些跨国企业为了降低 IT 基础设施成本，已经放弃了传统上采购预编软件和服务器的模式，在其全球基础设施和市场活动中，转而采用一种以 WEB 为基础的、由第三方托管的计算机设备和应用。越来越频繁的向云转移的活动会带来一个实质性问题，即云计算服务如何能够适应各国现有的税收体系。由于许多国家跟不上技术发展的步伐，在决定云计算的可税性方面只能采取一些前后矛盾的、拼凑起来的方式，它们要么将现存的涉及有形个人财产、服务、信息或者数据处理的相关规定适用于云计算上，要么直接套用针对传统电子商务征税的模式。在这种背景下，一方面，云服务的提供者以及他们的客户在如何适用一国税法规则来判定自身的纳税义务方面缺乏明确的指引。他们并不清楚：云计算服务是否需要缴税以及如何缴税。另一方面，各国在对待这些问题上面还可能会给出不同的解决方案。这给跨国云计算服务的税务处理带来了极大的挑战，尤其是在处理跨国云计算服务营业利润课税权分配的问题上。在现行国际税收体制框架下，常设机构原则仍然是国际社会应对数字化经济时代税收管辖权的基本原则。然而，不断加剧的国际税收管辖权冲突，使得来源地税收管辖权和居民地税收管辖权都有所弱化，各国在云计算服务营业利润课税权分配问题上的争议不断。显然，常设机构原则这种适用于传统物理经济运作模式的税收管辖权方案对解决云计算服务相关问题方面已经力不从心。有鉴于此，有必要寻求一种新的税收管辖权方案来应对跨国云计算服务营业利润课税权分配的问题。通过探讨对国际税收制度中管辖权问题产生深远影响的 Piedras Negras 案例，可以从中获得处理跨国云计算服务营业利润课税权分配问题的重要启示。因此，文章从跨国云计算服务营业利润课税权分配规则适用面临的困境出发，详细评析了 Piedras Negras 案及在此基础上形成的跨国云计算服务营业利润课税权分配的传统规则——常设机构原则，重点梳理了云计算的基本概念、特征、主要模式以及传统的电子商务商品交易模式与云计算服务交易模式的区别，并通过案例分析提出各国在应对跨国云计算服务营业利润课税权分配问题上可供借鉴的新对策。最后，结合我国云计算发展的现状和实际国情，为我国处理跨国云计算国际税收管辖权问题提出了几点建议。

关键词：营业利润课税权；贡献；税收利益分配 ；预扣税；再分配

Abstract

In today's technology-driven economic development, especially with the rise of cloud computing,some multinational enterprises have abandoned the model of traditional procurement preprogramming software and server hardware in their global infrastructure and market activities in order to reduce the cost of IT infrastructure. Instead, they have adopted a web-based, third-party hosted application. The increasingly frequent activities of transfer to the cloud will bring a substantial problem, that is, how cloud computing services can adapt to the existing tax system of states. Because of inability to keep up with the pace of technological development, many countries have to employ conflicting and patchwork ways to determine the taxability of cloud computing. Furthermore, They have even applied the existing rules relating to tangible personal property, service, information or data processing to the cloud computing, or directly use the taxation model of traditional E-commerce. In such context, on the one hand, the providers of cloud services and their customers are lack of clear guidance on how to determine their own tax obligations on the basis of a country's tax law. They don't know whether the cloud computing service needs to pay or how to pay taxes. On the other hand, countries may also give different solutions to these problems. This poses a great challenge to the tax treatment of transnational cloud computing services, especially in dealing with the allocation of the right to levy taxes on the business profits. Under the framework of the current international tax system, the principle of permanent establishment is still the basic rule for the international community to deal with the tax jurisdiction in the era of digital economy. However, the intensifying conflict of international tax jurisdiction has weakened the jurisdiction of the source and also the residents with constant disputes over the distribution of tax right on business profits over cloud. It is obvious that the tax jurisdiction scheme, which is applicable to the traditional physical economic operation model, is hard to solve the problems related to the cloud service. In view of this, it is necessary to find a new tax jurisdiction plan to settle the assignment of the right to tax business profits on transnational cloud. By discussing the Piedras Negras which has a profound influence on the question of jurisdiction in the international tax system, we can obtain the important enlightenment to deal with the distribution of tax rights of the operating profit of cloud service. Therefore, starting from the difficulties faced by the application of the distribution rules of the operating profit tax rights of the cloud, the paper explore Piedras Negras and on its basis the traditional rules of the distribution of the tax rights of the operating profit-- the principle of the permanent institution, mainly focuses on the basic concepts, characteristics, main patterns, the difference between the traditional e-commerce and the cloud service and proposes a new way for the tax right on operating profits of the multinational cloud. Finally, considering the current and actual situation of cloud computing in China, the paper puts forward some suggestions for China to deal with the tax jurisdiction of transnational cloud computing.

Key words:taxation right of business profits; contribution; allocation of tax interests; withholding tax; redistribution

目录

摘要 I

Abstract II

第 1 章 引言 1

1.1 选题的背景及意义 1

1.2 选题的研究内容 1

1.3 文献综述 1

1.4 研究方法 4

第 2 章 问题的提出 5

2.1 云计算的概念、特征及主要模式 5

2.2 云计算服务交易模式与传统电子商务商品交易模式的区别 6

2.3 跨国云计算服务营业利润课税权分配规则适用面临的困境 8

2.4 美国 Piedras Negras 案对解决跨国云计算服务营业利润课税权分配问题的启示 10

第 3 章 常设机构原则及其与云计算服务的不适应性 12

3.1 跨国云计算服务营业利润课税权分配的传统原则——常设机构原则 12

3.2 跨国云计算服务营业利润课税权分配的传统原则与云计算服务的不适应性 13

3.2.1 云计算服务不具备常设机构原则指导下实体经济的基础 16

3.2.2 常设机构原则导致云避税港的恶性税收竞争 16

3.2.3 常设机构原则与现代云计算技术的要求相矛盾 17

第 4 章 跨国云计算服务营业利润课税权分配之“整体事实”规则 18

4.1 “整体事实”规则的含义 18

4.2 “整体事实”规则的合理性 18

4.2.1 “整体事实”规则与税收方法理论的关系 18

4.2.2 “整体事实”规则与国家功能之间的关系 18

第 5 章 “整体事实”规则基础之上跨国云计算服务营业利润课税权的分配 20

5.1 跨国云计算服务营业利润课税权主体的确定 20

5.1.1 跨国云计算服务营业利润课税权主体的选择原则——“贡献”原则 20

5.1.2 跨国云计算服务营业利润课税权主体的排除——服务器所在地 21

5.1.3 跨国云计算服务营业利润课税权主体的实例展示 21

5.2 跨国云计算服务营业利润税收利益的分配方案——预扣税与再分配相结合的方案 22

5.2.1 单纯的预扣税方案及其不合理性.....22
5.2.2 预扣税与再分配相结合的方案之具体内容.....23
5.2.3 预扣税与再分配相结合的方案之可行性.....24
结语.....27
参考文献.....29
致谢.....30

第1章 引言

1.1 选题的背景及意义

我们所处的数字化环境正以一种二十年前我们无法预料的速度变化着，旧的税收制度已难以适应这种变化。云计算的兴起，引发了一系列的税务难题，尤其体现在处理跨国云计算服务营业利润课税权分配的问题上。在现行国际税收体制框架下，常设机构原则仍然是国际社会应对数字化经济时代税收管辖权的基本原则。然而，不断加剧的国际税收管辖权冲突，使得来源地税收管辖权和居民地税收管辖权都有所弱化，各国在云计算服务国际税收管辖权分配问题上的争议不断。显然，常设机构原则这种适用于传统物理经济运作模式的税收管辖权方案已经无法适应于云计算时代。因此，在云计算环境下，如何有效应对跨国云服务营业利润的课税权问题，不仅一直是国际税收制度的空白点，也成为各国决策者亟待解决的税务问题。国际税收制度的这种不确定性给云计算服务公司避税提供了可乘之机，大量税收随之流失，加剧了全球税基的侵蚀和双重不征税现象。有鉴于此，论文试图通过探讨对跨国云计算服务营业利润课税权分配问题产生深远影响的典型案例 Piedras Negras 案，[①]从而提出一种可供国际社会在处理此类问题的参考方案。

1.2 选题的研究内容

论文试图通过探讨对国际税收管辖权分配规则产生深远影响的 Piedras Negras 案例，从而提出可供国际社会在处理跨国云计算服务营业利润课税权分配问题上参考的重要经验。论文旨在从 Piedras Negras 一案出发，详细地介绍在此基础上形成的跨国云计算服务营业利润课税权分配的传统对策并对此进行评析，重点梳理云计算的基本概念、特征、主要模式及其演变历程，分析传统的电子商务交易与云计算服务交易的区别，并提出各国在应对跨国云计算服务营业利润课税权分配问题上可供借鉴的新对策。最后，结合我国云计算发展的现状和实际国情，对我国跨国云计算国际税收管辖权规则进行展望，以便为我国的相关立法与司法实践提供可操作性、符合发展趋势与潮流的解决方案。

1.3 文献综述

目前，如何应对云计算技术带来的征税难题，降低全球税基的侵蚀和双重不征税风险成为国际社会最具挑战性的课题之一，亟需回应立法、司法实践与现实需要。美国作为最大的云计算市场以及信息技术最发达的国家，其有关云计算服务国际税收管辖权分配的规则无疑也最值得关注。然而，作为一门新兴的课题，对云计算该不该征税、采取何种方式征税以及各国间税收管辖权分配这些最具争议性的问题，无论是 OECD 范本、UN 范本还

① Commissioner v. Piedras Negras Brodcasting Co.

是美国税法在应对这些问题的过程中也显得无所适从。大多数的研究还停留在探讨传统电子商务征税模式的问题上，甚至对电子商务征税模式的研究还不够完善。在数字化经济环境下，云计算交易作为一种特殊的商品和服务交易，本质上属于电子商务，在实质上它与传统电子商务模式下其他无形产品的交易一样，都颠覆了利用常设机构原则来确定营业利润管辖权的规则，但云计算交易的模式又不同于一般性的无形产品，属于新型电子商务的范畴。总体来看，有关云计算服务的研究主要针对其可税性问题、常设机构的认定、有形无形财产的定性、所得来源的认定及管辖权冲突问题。尽管研究涉及管辖权问题，但研究也主要针对管辖权冲突的原因、影响等加以探讨或者提出一种总体的解决方案，即使有些学者建议对跨国云计算服务课征预扣税的方案，但该方案并不具体细化。

与国外研究相似，国内目前研究也主要针对电子商务环境下所面临的税收问题、税收制度、各国的政策和对策的具体问题，而较少涉及云计算条件下有关国际税收方面的问题。研究成果主要有：

张丽芳在“跨境云计算的国际税收问题”一文中较为深入地探讨了跨境云计算商业模式带来的挑战。首先，作者认为跨境云计算引发了国际税收管辖权的冲突：在云计算环境下，按照现行的征税模式，服务器所在地为收入来源国（服务器是一种常设机构），而现实中往往存在服务器位置与服务需求方所在地不符的情况，以服务器作为常设机构可能造成只有服务器所在国可行使收入来源管辖权，消费国没有征税权。这有违税收公平原则，也会加剧服务商的避税活动。其次，有关常设机构的认定：作者认为云计算技术的复杂性使得提供相应服务的服务器位置难以准确预判，因此会对常设机构的认定造成困难。再次，有关利润归属的判断：因服务商难以准确记录服务的使用信息，因而难以判断有多少利润可归属于某个国家的服务器。在文章最后，作者提出了云计算征税的方案，即放弃传统上常设机构概念原则，课征预提税的征税思路。①

廖益新在“数字经济环境下跨境服务交易利润国际税收原则与方案”一文中较为全面和深入了剖析了数字经济背景下跨境服务贸易的国际税收权益分配问题。作者在文章的第一部分首先提出了应对电子商务税收应当遵循的五项基本原则，即税收中性、效率、确定和简化、有效和公平以及灵活适用。并在此基础上认为：这五项基本原则之间存在着内在的矛盾，任何解决数字经济背景下跨境服务贸易的国际税收分配问题的对策方案都不能苛求它能够同时在同等程度或范围上满足这五项基本原则的要求，必须折中权衡、有所取舍。跨境数据化服务贸易的国际税收规则应符合国际税收权益分配公平合理原则。作者在文章的第二部分提出了跨境服务贸易利润国际税收权益分配的预提税方案，即在销售市场所在国按客户支付毛额的6%从源扣缴的预提所得税，并且数据化产品或服务的销售方的居住国应依法予以提供消除国际重复征税的救济以避免国际重复征税。作者在第三部分主要针对该预提税方案的正当合理性和可行性进行了分析。②

① 张丽芳.跨国云计算的国际税收问题.国际税收[J].2014(8).
② 廖益新.数字经济环境下跨境服务交易利润国际税收的原则和方案.国际经济法学刊[J].2014(3).

可以看出，尽管理论界与实务界就电子商务国际税收问题关注不少，研究成果颇丰，但对云计算的税收问题还处在探索阶段，缺乏全面系统性的研究。就目前的研究成果来看，针对网络服务活动，在数字化经济环境下提倡放弃传统常设机构概念原则，课征预提税方案受到多数学者的青睐，但几乎没有学者提出一种具体的、现实可行的管辖权分配方案。笔者认为，6%的预提税方案并不能达到使云服务商放弃避税活动的目的，不能改善全球税基侵蚀的现状。为了使纳税人在进行投资时不必从税率的高低考虑，最理想的状态就是资本输入国与资本输出国的税率之和等于资本输出国国内实行的税率。就跨国云计算服务营业利润课税权分配问题而言，实现资本输出中性是征税模式合理性的理论支撑。

就电子商务税征税模式来说，在过去的 15 年里，有几种可供选择的方案建立在资本输出中性理论基础之上。这些方案共同的思想基础均是在消费地实行预扣税。 学者 Avi-Yonah 在其“INTERNATIONAL TAXATION OF ELECTRONIC COMMERCE”一文对传统电子商务实行预扣税的方案进行了详细地分析。他认为，预扣税的主要目的就是为了确保各国间公平分配税收权益，一个企业至少要在一国纳税。作者还认为，在消费地征收预扣税只能就一个企业在产品生产地未被征税的毛所得按照公司税率课征。而且，如果企业在消费地进行了纳税申报，则可按其净所得计征。这种预扣税方案既可针对 B2B 交易，也能适用于 B2C 交易。[①]

继 Avi-Yonah 首次提出其预扣税方案之后，学者 Doernberg 在“ELECTRONIC COMMERCE AND INTERNATIONAL TAX SHARING”一文中提出在消费地征收 10%的预扣税方案。作者指出，任何侵蚀公司税的跨境支付都应在消费地课征预扣税。这种预扣税方案一般适用于 B2B 交易，但不限于电子商务交易。[②]

学者 Cockfield 基于现行国际税收协定预扣税条款的规定，提议对电子商务征收 5%的预扣税。作者认为，由于电子商务特殊的本质，尽管一个公司在消费国没有常设机构，大部分电子商务活动仍可以在消费国完成。因此，作者认为这种预扣税方案仅适用于 B2B 交易，因个人电子商务预扣税方案在实际中难以执行，不适用于个人电子商务。[③]

总之，不管是 Avi-Yonah、Doernberg, 还是 Cockfield、Reihold,[④]他们理论首要的共同之处在于都意识到服务或无形商品的消费国有合法征税的权利。除了 Avi-Yonah，其他三位学者提议的预扣税税率均相对较低，而且课征的预扣税在居民国可享受抵免。学者 Avi-Yonah 预扣税方案的主要目的是阻止服务提供者因传统的收入来源规则存在漏洞进而避税导致税基侵蚀的严重后果，而不是试图改变各国间税收权益分配的现状。其次，他们理论的第二个共同点是认识到需在消费地课征预扣税。再次，四位学者均认为服务提供者的居民国理应享有优先的征税权，其次才是消费国。因此，消费地只能征收小部分税。当然，学者 Avi-Yonah 建议全部所得均需在消费地暂时缴纳预扣税。最后，除了 Doernberg,

① Reuven S.Avi-Yonah. International Taxation of Electronic Commerce. 52 TAX L.REV.507(1996).
② Richard L. Doernberg. Electronic Commerce and international Tax Sharing. 16TAX NOTES INT'L 1013,1013-22(1998).
③ Arthur J. Cockfield. Balancing National Interests in the Taxation of Electronic Commerce Bsiness Profits. 74 TUL.L.REV.133(1999).
④ Richard L.Reinhold. Some Things That Multilateral Tax Treaties Might Usefully Do. 57 TAX L.661(2003).

其他学者均建议：为便于管理，预扣税方案应当在所得最低临界值之上适用。

不难发现，以上理论的实质即放弃传统的常设机构概念原则，采用预提税的国际税收权益分配方案。但如果将以上学者 Doernberg、Cockfield 以及 Reihold 的建议全盘适用于云计算服务，即消费地按照 10%或更小的比例参与税收权益分配，或者采纳廖益新教授的观点，即在消费地课征 6%的预扣税，[①]都不能促使一些低税率国家或地区放弃对云服务继续推行“避税天堂”的税收优惠政策。因此，笔者认为在借鉴以上学者提出的建议时，我们必须寻求一种可消除低税率影响的解决方案。论文试图从云计算服务的本质出发，批判地借鉴以往学者提出的电子商务的征税方案。

1.4 研究方法

论文以唯物主义辩证观的基本原理以及马克思主义法学思想为指导，运用税收民主理论，坚持理论联系实际的原则，采用案例分析、历史分析以及对比分析法对论题进行探讨，努力做到在研究视野、内容以及方法上有所创新。

① 廖益新. 数字经济环境下跨境服务交易利润国际税收的原则和方案. 国际经济法学刊[J]. 2014(3)

第 2 章 问题的提出

随着信息技术革命的发展，公司所得税税基侵蚀日益严重，全球经济在这次革命的洗礼中发生着翻天覆地的变化。云计算技术，又称云，是信息技术的一个分支。云计算的出现改变了传统的商业模式。现在，商业活动不再局限于本地，多地的企业和客户完全可以凭借云计算技术实现远程交易。[①]不仅如此，商业组织甚至可以将其 IT 基础设施（网络服务器）分散布局在世界各地，而这些服务器通过网络连接的任意设备和标准的网络浏览器就能轻松加以管理和控制。这给国际税收制度和国际税收协定提出了前所未有的困难和挑战。同时，伴随着信息技术的突飞猛进，国际税收制度的这种不确定性给云计算服务公司避税提供了可乘之机，大量税收随之流失，加剧了全球税基的侵蚀和双重不征税现象。在云计算环境下，如何有效应对跨国云服务征税的难题，妥善处理各国之间云计算服务营业利润课税权分配的问题，不仅一直是国际税收制度的空白点，也成为各国决策者亟待解决的税务问题。

然而，现行国际税收制度是为适应 20 世纪初期的商业模式而设计的。那时，商业活动的对象还是实物，交易双方所在的地点也十分明了。可以这么说，“你所见即你所得”。但美国 Piedras Negras 案却给我们提出了难题：该案涉及的交易所得的分类以及交易地点都难以确定。尽管如此，该案的判决仍然没有突破现行国际税收制度关于常设机构原则的理论基础。几十年来，该案作为对云计算服务营业利润课税权分配规则影响最大的案例，美国以及其他国家不仅一直忽视其中存在的税收管辖权问题，而且还用于指导国际法律实践。毋庸置疑，随着信息技术的发展，20 世纪初形成的国际税收管辖权制度已经无法适应云计算技术的发展要求，必须要在国际社会广大成员达成一致共识的基础上为云计算服务专门建立一种能被各国普遍接受的新的税收管辖权规则体系，尽可能实现国际税收权益分配公平合理。

2.1 云计算的概念、特征及主要模式

“美国商务部国家标准与技术研究所对云计算的定义：云计算是这样一种模型，它可以实现随时随地，便捷地，随需应变地从可配置计算资源共享池中获取所需的资源（例如，网络、服务器、存储、应用及服务），资源能够快速供应并释放，使管理资源的工作量和服务提供商的交互减小到最低限度。该定义表明云计算具有五个基本特点：（1）随需应变地自助服务（2）无处不在的网络访问（3）资源共享池（4）快速而灵活（5）计量付费服务”。[②]通俗地说，云计算就是公司和个人通过向云计算服务商支付使用费而从云计算服务商那里获取数据存储空间、计算平台、数据库或软件的能力。

---

① 崔晓静、赵洲. 数字经济背景下税收常设机构原则的适用问题. 法学[J]. 2016(11).

② Stephen J.Lusch. State Taxation of Cloud Coputing(2013). http: //heinonline.org.

云计算服务有三种不同的模式：SaaS、PaaS 以及 IaaS。第一种模式是软件即服务模式。这种模式对大多数经常使用网络邮件、日历、文字处理以及数字应用的互联网用户而言最熟悉不过了。这种模式的云服务提供安装、操作以及维护云基础设施之上的应用软件，而消费者能够通过客户端（比如台式电脑、笔记本电脑、平板电脑和智能手机）访问。应用软件仅存在于云服务商的服务器上，通过互联网客户端接口（通常是网页）能够被访问。一般而言，用户不能安装、下载或转移应用软件到他们自己的计算机上。除了有限的、用户特定的配置设置以外，用户并不能实际控制底层的云基础设施，包括“网络、服务器、操作系统或单个的应用功能。SaaS 是终端客户应用最广的一种云计算模式，由于这种云计算服务使用起来不需要运用任何底层程序编码或技术架构方面的知识，因此，它既可为个人用户（B2C）服务，也可为企业用户（B2B）服务。Google Drive, Microsoft Office365 等都是 SaaS 云服务的例子。[①]

除了 SaaS，云计算还包括 PaaS 或 IaaS 模式。它们与 SaaS 的区别主要在于提供的服务不同。这两种云计算服务模式是为 B2B 设计的，更适合于软件开发者以及服务提供者。通过这种云计算服务，他们可向终端客户提供 SaaS 服务。其中，PaaS 模式的云服务，是消费者在不购买和管理底层硬件和软件层的情况下，利用资源提供者指定的编程语言、服务以及工具，部署自己创建的应用。例如，Salesforce 就允许企业用户使用其平台部署自定义的软件。IaaS 模式的云服务提供基本的计算能力、存储以及网络带宽，用户即使不购买底层基础设施，也可以在上面部署和运行软件，包括操作系统和应用程序。Netflix 就是一个很好的例子，其将服务托管在亚马逊的云上，但它并没有属于自身的硬件设施。[②]

云时代的到来表明我们用来储存信息以及运行应用程序在方法上发生了重大转变。用户很少在个人计算机上运行程序、储存数据，而是将这些程序和数据托管在这个可以通过网络访问的、由许多电脑和服务器的随机组合的云之上。云计算将多个公司的服务器和网络连接在一起，通过网络可以随时随地访问各种服务和存储。用户在计算机本地储存的所有信息都可以在云端储存。这为企业跨区域经营提供了便利。

2.2 云计算服务交易模式与传统电子商务商品交易模式的区别

云计算是信息技术发展到一定阶段的产物，它的出现模糊了虚拟空间与实体空间之间的界线。在数字化经济环境下，云计算交易作为一种特殊的商品和服务交易，本质上属于一种电子商务，但又区别于传统的电子商务，属于新型电子商务模式的范畴。因此，研究云计算服务的营业利润课税权分配问题对于解决电子商务乃至数字化经济相关领域的问题具有重要的意义。而明确云计算服务交易与传统电子商务商品交易之间的区别是解决云计算服务营业利润课税权分配问题的第一步。

以软件为例，在传统的电子商务软件交易中，软件开发者往往需将软件的所有权转移

① 张亚勤等主编. 云计算 360 度——微软专家纵论产业变革[M]. 北京：电子工业出版社. 2013:63.
② Gil Savir. A Suggested Framework for the Taxation of Cloud Computing(2015). https: //papers.ssrn.com.

给买方。而在云计算环境下，客户不能取得软件产品的所有权。客户购买的只是访问软件程序的权限。表一对传统电子商务软件交易与云计算服务软件交易作了比较，从该表可知：对于传统的电子商务软件交易，客户可以获得实物载体的软件产品（比如可视的 CD、DVD），或者客户可以自行从软件开发者的网页上下载软件。通常，一旦客户得到了这些软件，交易即结束。当然，在某些情况下，客户成为会员或支付一定的费用也可以获得后续定期的软件更新服务。然而，云计算服务软件是作为一种服务提供的，比如微软的 Office365。Office365 是微软公司跨多个服务器网络开发并面向世界各地发行的一款套装软件。微软公司通过复杂的运算有效地利用网络资源，无缝自动路由该软件的所有操作，因此，客户并不清楚软件的具体地址，也无法选择在某个特定的服务器上进行操作。

表一 传统的软件交易与云计算服务软件交易之间的区别

	传统的电子商务软件交易	云计算服务软件交易
交付方式	物理磁盘或下载	客户登陆网页访问软件
安装方法	客户自行安装	由软件开发者安装，客户使用用户名和密码访问
升级	使用者管理和控制	软件开发者管理、控制软件升级
硬件	客户电脑需由软件开发者进行匹配设置来运行软件。	运行软件的硬件设施由云计算服务公司提供，因此，客户仅需极少的硬件条件来操作软件。
支付方式及协议终止	不管是销售还是许可，软件公司都很难控制客户是否按照销售或许可协议的规定使用软件。	按月或按年订阅。一旦客户失约，云计算服务公司即可停止其继续访问软件。

在硬件方面，传统的电子商务硬件交易主要涉及那些能够扩大数字化信息存储空间或者提高处理能力的有形设备。用户购买这些设备能够获得它们的所有权。而在云计算服务的场合，个人及企业则从云储存服务提供者那里租赁虚拟的存储空间以供他们存储数字化数据，或者按需租赁额外的处理能力。从表二可知：在传统的硬件交易中，消费者想要获得额外的数字化存储空间就必须到实体店购买存储设备（比如硬件驱动，USB 或 SD 卡）。同时，也可以通过亚马逊、易贝、阿里巴巴等电子商务平台购买这些设备。当然，现在还有另一种选择：目前，一些平台，比如百度以网盘的形式提供各种虚拟的存储服务。在这类交易中，服务器被设置于某地，客户能够获得的不是存储设备的所有权，而是存储网络的部分虚拟空间。

表二 传统的电子商务硬件交易与云计算服务硬件交易之间的区别

	传统的电子商务硬件交易	云计算服务硬件交易
交付方式	邮寄	提供访问的渠道
安装方法	客户自行安装或电脑技术员帮助安装	云计算服务公司安装
升级	长期使用需购买新的硬件	与云计算服务公司达成新的协议——通过改善硬件配置升级
维护	客户自行维护或者电脑技术员帮助维护	云计算服务公司
支付方式及协议终止	一次性支付	按月支付

2.3 跨国云计算服务营业利润课税权分配规则适用面临的困境

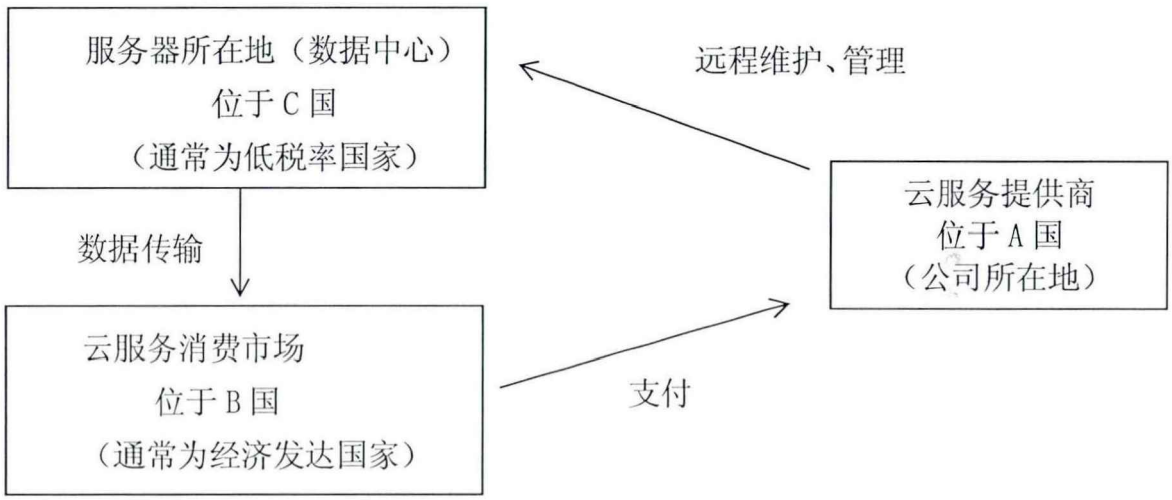
随着互联网的普及，云计算对我们生产生活发挥着越来越重要的作用，在国民经济中的地位举足轻重。云计算服务和数据无疑代表了计算机发展的潮流和趋势。尽管许多发展中国家的云计算行业还处于发展的初期阶段，但随着世界经济由生产型向服务型转变，在不久的将来，云计算行业必将占据越来越重要的经济地位。税收利益的分配无疑会成为各国争议的焦点。因此，寻求能够解决跨国云计算服务营业利润课税权冲突的途径以及协调好各国间税收管辖权的分配显得尤为重要。然而，自20世纪90年代以来，国际税收制度的关注点一直是如何将传统的税收制度适用于传统的电子商务交易，既包括通过亚马逊、易贝等在线平台购买实体商品的交易，也包括以下载交付的方式购买无形商品（数字化文件，比如游戏、电子书、图片、电影、音乐或软件程序）的交易。其中，如何对通过电子商务平台远程交易的一般性无形商品征税以及如何避免双重征税一直是各国着力求解的焦点，但并没有针对新兴的云计算服务如何征税提出任何可供具体操做的指导性规则。在现行国际税收体制下，常设机构原则仍然是国际社会应对传统电子商务交易乃至云计算交易营业利润课税权分配的基本原则，即依照非居民是否在一国境内拥有常设机构来判断一国对其是否具有征税权。事实上，传统的常设机构原则已不能满足传统电子商务发展的需求，[①]况且，云计算服务交易模式与传统电子商务商品交易模式之间还存在较大的差别。因此，在云计算环境下，常设机构的认定无疑给国际税收制度提出了更大的挑战。

跨国云计算服务营业利润税收权益分配问题最为核心的当属税收管辖权问题,“因为税收管辖权是确定国家之间税收权益分配的基础”。[②]正如我们所了解的，“主权国家对纳税人一项所得是否具有征税的权利是根据属人原则和属地原则进行划分的。与此相对应，

① 王洪良.跨国电子商务中国际税收管辖权的冲突与对策.国际经贸探索[J].2007(9).
② 梁学平、李平.电子商务环境下国际税收利益的分配问题研究.当代财经[J].2003(1).

在国际税收法律实践中，各国也都以征税对象是否与本国存在某种属人属性和属地属性的联结关系，来判断本国是否应该行使税收管辖权。国际上所得税税收管辖权通常可以归为两类：即所得来源地税收管辖权和居民税收管辖权。当然，美国主张将所得税税收管辖权分为三类：所得来源地税收管辖权、居民税收管辖权以及公民税收管辖权”。[①]就云计算服务而言，因云服务商可以任意在世界各地建立数据中心，往往会出现服务器所在地、企业所在地以及消费市场所在地不一致的情形。事实上，许多跨国云服务公司，为了降低生产成本，最大限度获取利润，也会选择将服务器布局在一些低税率的国家。图一描述了简化的云计算运作模式。在这种模式下，来源地税收管辖权和居民税收管辖权都变得难以确定。首先，由于云计算交易活动的虚拟性，突破了传统上常设机构原则指导下要求以实体存在来判断收入来源的标准，使得来源地税收管辖权界限模糊。同时，传统上各国判断法人居民身份的标准是存在有形机构，而在云计算环境下，有形机构不再是云服务商进行经营活动必不可少的条件。即使存在有形机构，为了追求利润最大化，它们也可以随意按需转移这些有形机构。居民税收管辖权无疑也遭到了严重的冲击。[②]

图一



因此，要解决跨国云计算服务营业利润课税权的冲突和争议，判断收入的来源是至关重要的。因为只有交易所得的来源国才有权对该所得征税。以美国为例，如果交易所得来源于美国，美国就具有了排他的征税权，外国公司就有义务向美国缴税。同时，由于美国可以就其公民和居民来自世界范围内的所得征税，如果美国公民外国来源的所得按照外国税法缴税的，就有资格获得外国税收抵免。当然，多个国家的来源规则还必须相似才能避免对相同所得重复征税。

① 蔡庆辉.电子商务环境下国际税收协定所得分类规则适用问题研究.厦门大学法律评论[J].2001(1).
② 廖益新主编. 国际税法学[M]. 北京：高等教育出版社，2008：65.

2.4 美国 Piedras Negras 案对解决跨国云计算服务营业利润课税权分配问题的启示

探讨跨国云计算服务营业利润课税权分配问题必须提到的另一个问题就是所得性质的分类。不同性质的所得分类会影响国际税收协定相关条款的适用。在云计算所得性质的界定上，各国的界定可能不同，但根据现行 OECD 范本，大多数云计算服务被界定为营业所得。在美国，由于缺乏相关的规定，多数美国学者倾向于按照美国国内税法 7701（e）部分将其归类为提供服务的所得。因此，本文对 Piedras Negras 案的讨论建立在云计算服务所得的性质在美国被界定为提供服务所得的基础上。诚然，尽管各国在收入性质的界定上略有差别，但无论是美国税收协定范本还是 OECD 或 UN 范本，都采用了类似的来源规则。美国税收协定中关于提供服务的所得与 OECD 和 UN 范本中关于营业所得在确定税收管辖权时都适用营业利润条款和常设机构条款。鉴于这种相似性，在 Piedras Negras 案的基础上来探讨云计算服务营业利润课税权的分配才有意义。

事实上，美国税法对各类交易所得的来源并没有成文的规则指引。[①]几十年来，美国税法却一直存有一个根深蒂固的非成文规则：1923 年，由四位经济学家组成的委员会发表的一份报告说明了国际税收中应当适用的征税原则。该报告建议所得的来源应当根据纳税人的主要经济活动进行确定。[②]综观美国税法，其中一些来源规则按照主要经济活动原则确定的来源又通过区分主动收入和被动收入的不同情形对此进行了明确的解释，但还有一些来源规则没有提供任何解释。比如，美国税法规定：提供服务的所得一般来源于履行服务的地方。[③]在这个规定中就没有明确解释履行服务所在地具体所指。正是在这种缺乏法律指导的背景下，美国法院根据常设机构原则对 Piedras Negras 案做了判决。在云计算环境下，由于没有明确的来源规则指引，美国法院就可能习惯性地类推适用 Piedras Negras 案的观点来应对云计算的征税问题。

在这个案件中，Piedras Negras 是一家广播公司，从墨西哥向美国客户提供广播和广告服务。美国第五巡回上诉法院认为，提供广播服务的外国纳税人取得的全部所得都属于外国来源的所得，即使超过 95%的所得都来自美国的广告商。不管广播服务的听众或广告商在哪，所得的来源地应当取决于纳税人固定资产以及劳动投入的所在地，而墨西哥是固定资产和劳动投入所在地（即服务器和公司所在地），因此所得来源于墨西哥。这种观点也是 Piedras Negras 案多数人所持的观点。

然而，也有少部分人认为：所得来源的认定不应当过多地考虑服务器的所在地。如果将分析的焦点仅仅放在服务器所在地，极易导致纳税人利用所得来源规则来规避对其不利的因素，而不是如实地反映交易活动的经济状况，尤其是当服务器可以位于世界任何一个角落的情况下，这一问题就会变得更加明显。因此，他们认为，服务器所在地只能作为考虑纳税人所得来源地的因素之一。另外一些因素，比如为经营活动所必需的辅助性服务或

① Lawrence Lokken.What is this Thing Called Source?28(2011). http://papers.ssrn.com/abstract=1795256.
② Report on Double Taxation,League of nations Doc.E.F.S. 73 F.19(1923).
③ 参见美国国内税法 § 861 (a) (3).

消费地，也应当加以考虑。具体到本案，即广告传输服务不应被单独看待，而应将其与纳税人经营所必需的各种活动与其他事实结合在一起加以考虑。这些需要考虑的因素和事实包括为接收通信费和广告费而使用的美国地址和邮箱、纳税人的代理人每日来往美国收账及分账的事实以及合同纠纷发生地在美国的事实。这些都可以证明纳税人在美国从事了经营活动，所得来源于美国。[①]

总的来说，Piedras Negras 一案是非常有意义且影响深远的。根据多数人的观点，该案为传输服务所得的来源提供了明确的解释，即按照主要经济活动原则将服务履行地确定为固定资产和劳动投入所在地。这给税收制度提供极大的确定性，对处于发展初期的美国国际税收制度十分重要。然而，随着信息技术的发展，美国继续沿用这种坚持了近百年的税收管辖权规则来应对跨国云计算营业利润课税权问题是否还具有合理性？与之相反的是该案中少数人所持的观点。在云计算环境下，此种观点是否也具有其适用的价值呢？对这两个问题的回答，已经成为国际社会亟待解决的课题之一。因为无论是美国税收协定范本还是 OECD 或 UN 范本，都采用了类似的来源规则。因此，在没有明确规则指引的情况下，各国也很可能参照适用 Piedras Negras 一案确定的管辖权规则来应对云计算服务的相关税收难题。而根据现行国际税收框架，也遵循以服务器所在地[②]作为所得的来源地。[③]在此背景下，通过探讨和分析 Piedras Negras 案所体现的管辖权问题对于解决跨国云计算服务营业利润课税权的分配问题有着十分重要的意义。

① James Carr & Jason Hoerner & Shirish Rajurkar & Chanin Changtor.Cloud Computing: U.S. Tax Compliance Complexity for Foreign Subsidiaries(2012).http: //heinonline.org.

② 服务器所在地也即固定资产所在地.

③ 张丽芳. 跨国云计算的国际税收问题. 国际税收[J]. 2014(8).

第 3 章 常设机构原则及其与云计算服务的不适应性

3.1 跨国云计算服务营业利润课税权传统分配原则——常设机构原则

按照传统理论，OECD 范本和 UN 范本在营业利润课税权分配问题上均采用了常设机构原则，即缔约国一方原则上不对非居民所取得的营业利润征税，除非其营业利润来自于该缔约方境内的构成常设机构的物理存在。[①]具体到 Piedras Negras 一案，该案法院最终采纳了多数人的观点，认为所得仅来源于广播服务的传输行为，而传输行为是在固定资产和劳动投入所在地被实施的，即固定资产和劳动投入所在地为服务履行地。在云计算环境下，美国法院类推适用该案多数人观点的结果，即服务器所在地和公司所在地为云服务的履行地，享有征税权，消费市场所在地因缺乏物理存在而没有征税权。与此同时，现行国际税收体制也默认服务器和公司所在地为所得的来源国。

在 Piedras Negras 案中，由于被告广播站在美运营非常成功，其负责人决定跨境经营并将广播站转移至墨西哥。因此，所有广播都是从墨西哥传送而来。然而，广播站的所有听众却都在美国，广播站的所有收入也来自美国的广告商。并且，该广播站的一位工作人员每隔几周都会到美国收取广告费。但第五巡回上诉法院认为，由于 Piedras Negras 公司在美国没有实体存在，该公司因广告而获取的所得就不是美国来源的所得，尽管广播站派遣了工作人员向美国的广告商收取了广告费。根据该法院的观点，广播站提供服务的地方应当是广播设施所在地（固定资产和劳动投入所在地），而这些设施都在墨西哥，因此服务是在墨西哥境内被履行的。而且，覆盖于美国范围内不受控制的电磁波因与美国缺乏实体关联，不能构成美国来源的所得。对此，法院解释称："如果广播所得是由几千公里内电磁波的传输行为产生的，由于电磁波传播行为从发出开始就不受发送者的控制和管理，所以，广播所得就源于传输行为。"最终，法院认为，被告所有的广播设施都不在美国境内，被告提供的所有与经营活动相关的服务都是在墨西哥履行的，因此，被告所有的经营所得都不是美国来源的所得。[②]

尽管该案判决发生在 1942 年，那时互联网还没有出现，但其已被美国公认为是与互联网领域最相关的案件之一，[③]在当时而言，Piedras Negras 一案以其明确而肯定的解释和结论给处于发展初期的国际税收制度提供了极大的确定性，从而使其成为影响深远的国际案件之一。但随着云计算时代的到来，其适用的合理性值得怀疑。

---

① 廖益新. 数字经济环境下营业利润课税权的分配. 厦门大学学报[J]. 2017(4).

② Fleming&J.Clifton.Electronic Commerce and the State and Federal Tax Bases.Brigham Young University Law Review (2000).

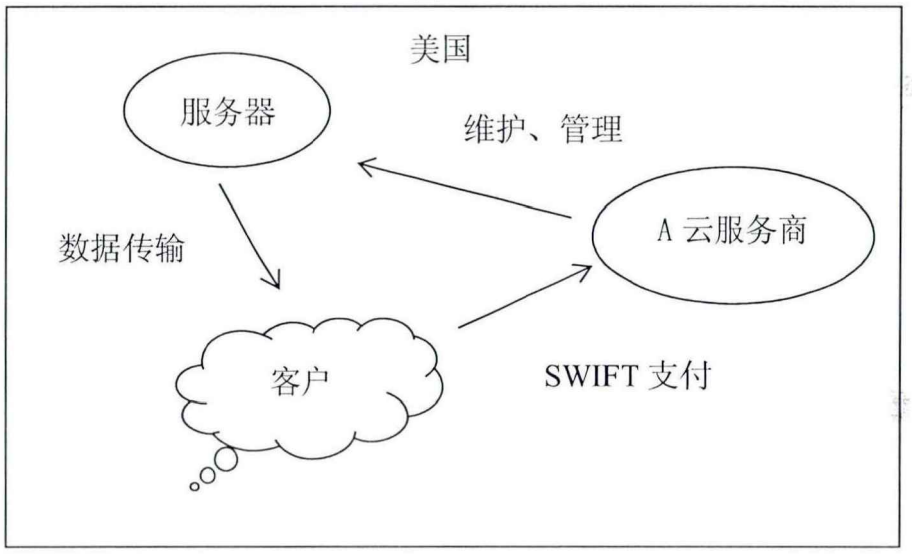
③ Gil Savir. A Suggested Framework for the Taxation of Cloud Computing(2015).https: //papers.ssrn.com.

3.2 跨国云计算服务营业利润课税权分配的传统原则与云计算服务的不适应性

正如上文所探讨的，如果类推适用 Piedras Negras 一案多数人的观点，云计算服务所得的来源即按照服务器所在地或者公司所在地确定。这也是现行国际税收体系默认的规则。然而，随着云计算技术的发展，法院能否继续适用 Piedras Negras 一案多数人的观点来确定云计算服务所得的来源值得怀疑。基于云计算的本质如何确定服务履行地以及哪个国家具有优先征税的权利，这些关乎服务履行地的问题就可能引发各国激烈的争论。为了说明这个问题，在此假定三种云计算服务的情形。[①]

第一种情形，云计算服务公司的所有运营活动都发生在一个国家——美国，客户也来自这个国家。如图二所示。在这种情形下，结论很明确：由于服务明显是在美国履行的，所以美国对服务所得具有征税权。

图二

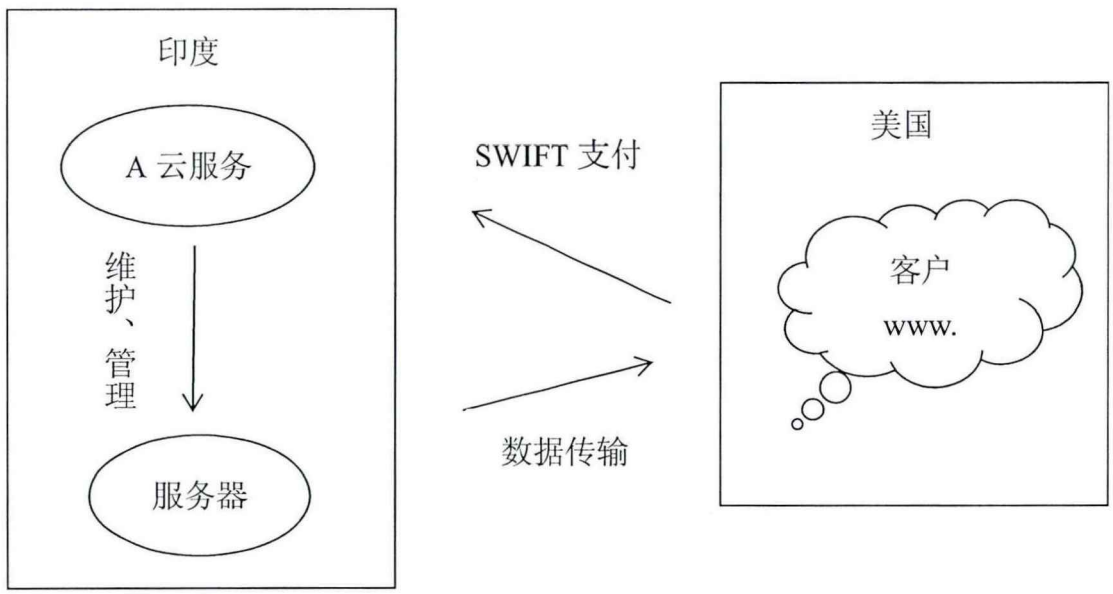


第二种情形，假设 SaaS 云服务公司 A 以及 A 公司的员工、服务器和银行账户都在印度，只有该公司的客户 B 是美国的一家公司。而且客户通过 SWIFT 付款至印度。如图三所示。在该云计算服务模式下，数据处理服务发生在云服务器上，然后数据通过电缆或无线传输线被发送至客户的计算机上，最终消费发生在客户计算机所在地。那么，云计算服务是在美国境内履行的还是在境外履行的？A 公司在印度境内传送云计算服务的事实能排除美国对该服务所得的征税权吗？事实上，这种情形与 Piedras Negras 案件既相类似，但又有区别。在 Piedras Negras 一案中，法院认为电磁波从发送那刻起就不受发送者的控制和管理并基于这个理由做出了判决。然而，在云计算技术的场合，数据传输时毫无疑问是受云计算服务公司控制的。而且，考虑到安全因素，所有由服务器传输的数据都会经过加密处理，从而确保只有特定的客户可以使用该数据。因此，传输至美国的数据都是明确指定发送给美国客户的。同时，云计算服务在传输给美国客户之前是在印度境内提供的。

① 张丽芳. 跨国云计算的国际税收问题. 国际税收[J]. 2014(8).

这些都表明，云计算服务不能被认为不受发送者控制和管理。如果按照主要经济活动原则确定所得的来源，该服务所得将会在印度被征税，因为所有经济活动都在印度进行的，而且印度是服务器所在地。然而，在云计算模式下，数字化数据的传输与无线电信号的传输存有诸多不同，而且数据传输只是影响传输过程诸多的因素之一。因此，将传输行为的实施作为判断云服务所得来源唯一的决定因素是不合逻辑的。

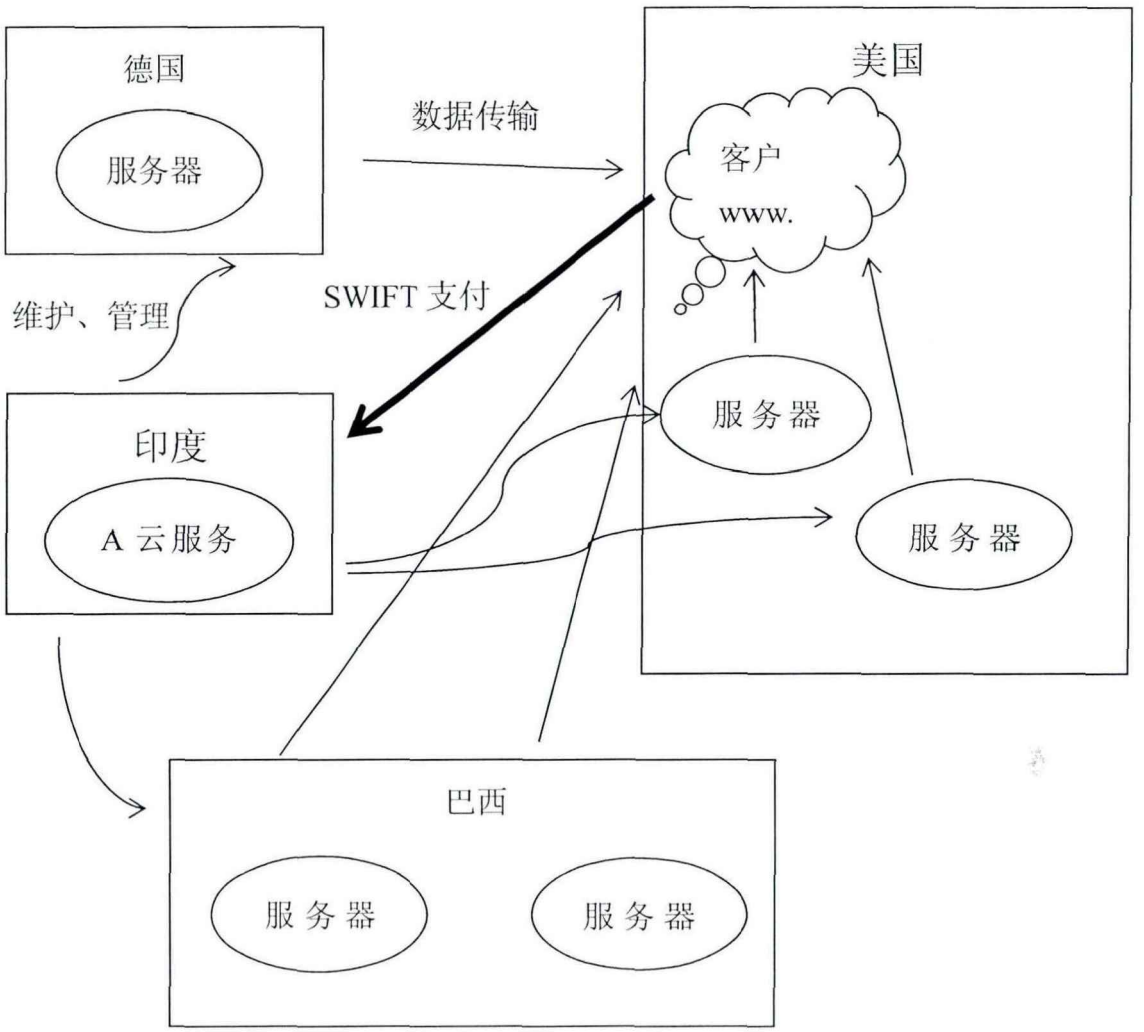
图三



第三种情形，假设 A 公司的云服务器分散布置在多个国家，而 A 公司及其员工、银行账户仍然留在印度。因为客户 B 公司需要大的网络带宽，A 公司将两个服务器设置在美国，一个设置在德国，还有两个在巴西。由此，提供云服务的服务器位于印度境外三个不同的国家，但所有服务器仍为 A 公司所有。如图四所示。这种情形与第二种情形又不同，会产生更多更复杂的税务问题。我们假设印度与巴西之间没有税收协定。根据 Piedras Negras 案件中多数人的观点，由于所得因传输行为的实施产生，A 公司提供云计算服务的所得应当由四国（印度、德国、美国以及巴西）共享，即分摊所得方案。然而，尽管所得可在四国之间进行分配，但仍存在不少问题。首先，各国间如何分配所得就不那么直接明了。各国都会拿出各自的理由认为自身应分配更多的所得：显然，因为 A 公司位于印度，印度理应认为大部分所得应归其所有。事实上，印度会要求就云计算服务的全部所得征税。美国和巴西会认为，分配给德国的所得应较少，因为德国仅托管了一个服务器。而德国则可能认为，尽管巴西有两个服务器，但德国境内的服务器承担了服务过程中的关键工作。其次，由于每个服务器的运作方式都不受 A 公司控制，如何认定各个服务器在服务过程中发挥了多大的作用也是一个问题。比如：是德国的服务器只处理了美国纽约用户的请求？还是无论是美国，还是巴西或印度的服务器都随机地提供服务？虽然根据每个服务器处理请求的数量来分配所得可能是一种可行的办法，但这种方法执行起来成本高昂，并不实用。之所

以会产生上述各种问题，是由于在云计算环境下云服务商以及它们的服务器和消费市场在哪几乎变得无关紧要，云服务商、服务器与消费市场完全可以分离存在。

图四



上述情形三采用的分摊所得的方案是根据 Piedras Negras 多数人的观点而得的。尽管这种方案存在不少问题，但仍有不少支持者。如果情形二也类推适用 Piedras Negras 多数人的观点，由于所有云计算运营活动都发生在印度而目标市场仅限于美国，类推适用的结果可能是所有服务的所得都应向印度缴税，因为云服务器和公司都位于印度。事实上，Piedras Negras 多数人的观点在云计算公司与服务传输地不发生分离的情况下是有一定的道理的。但采用多数人的观点类推适用于情形三，是在完全忽略其他因素（业务因素、经济因素、云计算的本质以及税收政策）的情况下，按照服务器和公司的位置对云计算服务所得分配课税权的方案，因而会产生极为不公平的结果。这种课税权分配方案无法克服以下几个方面的问题，其适用的合理性值得怀疑。

3.2.1 云计算服务不具备常设机构原则指导下实体经济的基础

常设机构原则建立在实体经济的基础之上，但云服务器所在地缺乏实体经济。服务器所在地的功能主要在于数据存储、处理和传输，在云计算技术下，管理和控制几乎都可以远程操作，这决定了云计算服务活动的虚拟性。这样，如果服务器所在地为所得的来源地，将很容易导致云计算提供者逃税和避税。因为云计算提供者重新安置服务器简便易行，完全可以通过转移服务器而避免在特定的国家纳税，但转移劳动力就要复杂困难得多。事实上，根据履行地来确定云计算服务所得的税收管辖权忽视了其他必须考虑的经济因素，因而，适用 Piedras Negras 多数人的观点不合逻辑。

3.2.2 常设机构原则导致云避税港的恶性税收竞争

忽视其他因素，仅将服务器和公司所在地作为确定所得来源地容易形成“云计算避税港”的新现象。[①]云计算服务提供者可以在世界范围内任意选择服务器的位置，如果云计算服务所得的来源按照服务器位置来确定，势必会鼓励一些国家实行各种税收减免优惠政策来吸引投资。这样一来，各国间可能形成恶性的税收竞争。1998 年，OECD 发表了一份题为“恶性的税收竞争，新兴的全球性问题”的报告，其中说明了大量关于恶性竞争的现象。[②]该报告还建议，21 世纪公司不应过度注重它们子公司的选址。否则，各国为了吸引企业投资，将加剧税收的恶性竞争。有人可能会认为，一国为吸引投资而采取税收优惠政策属合法的竞争。然而，现实的情况是，这些为了吸引外商投资而提供税收优惠的国家可能并没有将引进的外资用在本国。

毫无疑问，在云计算环境下，如果不考虑其他因素，继续依据 Piedras Negras 多数人的观点来确定云计算服务所得的来源，即将税收管辖权限定于服务器所在地和公司所在地是不合理的。尽管有些国家也会给予高新技术产业某种程度的税收支持，但云计算产业与高新技术产业不同，高新技术产业在当地必须有大量的专业技术人员，而云计算技术使得大部分的维护都能在另一地远程操作。因此，云计算带来的“云避税港”问题要比高新技术产业产生的避税问题严重的多。

而且，在有些情形下适用服务器所在地的税收管辖权原则会产生极为荒谬的结果。例如，某公司 C 位于巴西，各项经营活动也都在巴西进行，但服务器设置在以色列的一个子公司，且目标客户在美国。我们假设公司 C 将服务器安置在以色列是因为以色列极低的税率（以色列政府为了吸引该公司投资而向其提供的税收优惠）。显然，服务器选址最好是美国，因为客户是美国的。然而，出于降低税收的目的，公司 C 决定将服务器布局在税收条件最有利的地方。在本质上，服务是由巴西的公司开发的，市场在美国，而用以提供服务的基础设施在巴西、以色列和美国都有涉及。公司 C 与其子公司之间可以通过两种方案来管理服务器：（1）公司 C 可以向其以色列的子公司通过可接受的转让定价许可云计算软件；（2）公司 C 使用服务器，同时向其子公司支付一定的服务费。如果是许可的方式，许可的费用会比终端客户的价格低的多，因为云计算软件赖以生存的服务器是由以色列子

① Avi-Yonah. Globalization and Tax Competition: Implications For Developing Countries. at 4.
② 汪珺. 避税港和恶性税收优惠制度识别质疑——浅析 OECD 关于恶性税收竞争的报告. 税务与经济[J]. 2000(5).

公司控制的。如果适用 Piedras Negras 多数人的观点决定所得的来源，那么以色列就是所得的来源地。巴西顶多可分享其中实行独立交易价格的部分所得。结果，尽管客户是美国客户，费用也是在美国收取的，而且还利用了美国的法律系统、银行系统以及其他基础设施，但美国分配不到任何所得，因为无论公司 C 还是服务器都不在美国。因此，假如以色列不向云计算服务征税，世界主要的云计算服务公司都会想方设法在以色列建立子公司，尽管这样做对它们实际的经营活动没有丝毫意义。

3.2.3 常设机构原则与现代云计算技术的要求相矛盾

云计算技术依赖于国际的以及各国国内的公共互联网基础设施，这与 Piedras Negras 一案多数人观点的常设机构原则理论基础相悖。根据 Piedras Negras 一案多数人的观点，之所以认为传输服务的所得来源于传输服务的实施行为是因为，发送广播的无线电信号发射器是一个自治单元，这决定了其可以不依赖于目标国家的公共基础设施而在有限的范围内独立地进行数据传输。而云计算服务器传输数据的能力不受任何限制，其能将数字化数据传输到地球的任意地点。然而，这种不受限制的能力取决于国际的以及各国国内建立的互联网基础设施。另外，云计算提供者之所以能够将服务器设置在 A 国而只向 B 国的客户提供服务，原因就在于 A 国和 B 国都已经为其居民投资建设了广泛的互联网基础设施。尽管云服务企业在 B 国没有常设机构，但如果不利用 B 国完善的互联网基础设施，云计算技术在 B 国就无法实施。而在这个过程中，国家必须使用公共资源，同时也离不开一些私营部门的配合。通过向纳税人征税，国家才有资金投资这些基础设施建设。如果两国间的互联网基础设施高度完善，显然，不管服务器或公司位于何处，对客户都没有多大影响。

因此，以上事实说明，B 国也应是服务所得的来源国，因为提供云计算服务利用了 B 国的公共基础设施。也可以这么说，确定服务所得来源时，不应只考虑服务器或公司所在地。

第 4 章 跨国云计算服务营业利润课税权分配之“整体事实”规则

4.1 “整体事实”规则的含义

在云计算环境下，除了美国，大多数国家包括 OECD 在内的国际组织，也默认云计算服务器和公司所在地为所得的来源国。[①]如果继续类推适用 Piedras Negras 一案多数人的观点来决定交易所得的来源，会产生更多令人无法接受的结果。而该案少数人的观点给我们提供了另外一种思路。他们认为，确定交易所得的来源应当将所有涉及经营活动的因素都考虑在内，而不是只考虑固定资产和劳动投入所在地这个因素，所有因素应当视为一个整体，即“整体事实”规则。根据这种观点，确定服务履行地时应当考虑所有与经营活动相关的事实，所有事实视为一个整体。[②]服务履行地不仅包括固定资产和劳动投入所在地，其他涉及经营活动的地点也是履行地的一部分。换言之，就所得的来源地而言，消费市场所在地也应纳入所得的来源地。

4.2 “整体事实”规则的合理性

4.2.1 “整体事实”规则与税收方法理论的关系

事实上，少数人的观点对税法做了扩大解释。这与法律有些分析方法不符，因而可能会引起不少学者的争议。然而，实际上，这种观点是遵循法律立法宗旨的，而且也得到了税收民主原则的支持。

根据美国 1936 年税收法案 119 部分，也即现今 861（a）（3）/862（a）（3）部分，传输服务所得的来源地应为履行服务的地点。显然，在云计算的征税问题上，少数人的观点对税法作了扩大解释。有些坚持法律形式主义以及法律命令说的学者认为：“税法给纳税人强加了各种义务和限制，因而是一种恶法，就如同刑法一样。既然税法限制了纳税人的权利，就应对其作缩小解释。”

尽管如此，如果对税收民主原则进行全面地分析，我们便知少数人的观点是可取的。根据税收民主原则，在解释税法时，完全不顾该法的背景一味地追求缩小解释是十分荒谬的。上文例举的几种云计算征税模式恰好说明了这个问题。事实上，税法应当与其他法律（如合同法）一样采取相同的解释方式：即税法解释应当有助于实现立法的目的，同时允许纳税人参与税法解释的过程，保护他们个人的权利。很明显，Piedras Negras 一案多数人的观点是在完全忽视可能产生荒谬结论的情况下对税法作出的解释。

4.2.2 “整体事实”规则与国家功能之间的关系

除了得到税收民主原则的支持，“整体事实”规则还印证了有些学者提出的有关税收

---

① 廖益新. 数字经济环境下跨境服务交易利润国际税收的原则和方案. 国际经济法学刊[J]. 2014(3).

② James Carr & Jason Hoerner & Shirish Rajurkar & Chanin Changtor. Cloud Computing: U.S. Tax Compliance Complexity for Foreign Subsidiaries(2012). http: //heinonline.org.

制度中国家功能的三种理论：（a）最弱意义国家（b）服务型国家（c）福利型国家。

最弱意义国家是指国家的功能仅局限于保护人民的财产。因此，国家收取的税收只能用于保护人民的财产权利。[①]就云计算来说，毫无疑问，如果没有国家各部门（如银行、邮政、通信以及法院系统）提供的服务和保护，云计算服务就不能在一个国家正常进行。Piedras Negras 一案中，广播站和广告商之间曾约定：双方进行任何诉讼必须在美国提起。“整体事实”规则正是基于这个事实提出来的。因此，按照最弱意义国家的理论，如果客户位于美国，即使云计算服务公司及服务器都不在美国，为了保护该公司的所得，美国也有权就其取得的所得征税。

根据服务型国家的理论，为了维护社会安定和免受外国入侵，国家有权收税。而且，国家还可以向非营利性的公共服务征税。[②]毫无疑问，服务型国家模式下的国家同样也向云计算公司提供了最弱意义国家模式下国家为保护其互联网利益所提供的一切服务。而且，为了保护形成互联网骨干网的网络电缆，尤其是专用电缆，国家必须提供军队支持以及网络防御系统。事实上，网络电缆的保护就属于非营利性公共服务的范畴。

最后是福利型国家理论。[③]该理论认为，国家根据社会成员的能力进行征税。社会成员在国家的保护下获得了收入，因此，他们必须按照其收入所享受国家保护的程度缴税。按照这个理论的观点，很显然，由于云计算服务公司接受了国家的保护，因而必须缴税。

除了以上所述的几种国家理论，Piedras Negras 一案少数人观点的合理性也可以通过霍姆斯的“坏人理论”予以解释。由于坏人不受伦理道德的约束，“坏人理论”要求法律从一个坏人的立场出发，设想出各种可能的道德风险行为，明确行为边界，从而制定出规范人们行为的准则。由于云计算的部署大多是虚拟活动，如果没有目标市场国家的保护，云计算公司可能既不能也不愿在这个国家经营他们的网络活动。

因此，就云计算服务营业利润课税权分配而言，“整体事实”规则受到上述四种理论的支持，与 Piedras Negras 一案多数人观点确定的常设机构原则相比，具有后者无法比拟的优越性。

---

① 刘笑. 诺齐克“最弱意义国家”理论探析. 渭南师范学院学报[J]. 2012(1).

② Richard A. Musgrave. International Tax and Public Finance: The Role of the State in Fiscal Theory. volume 3. at 248.

③ 德国官房学派(财政学者)尤斯蒂(J.Justi)最早提出了“福利国家”的思想，主张通过国家的行政权力来实现福利国家，国家的财政支出是社会福利的基础.

第 5 章 “整体事实”规则基础之上跨国云计算服务营业利润课税权的分配

“整体事实”规则认为，在决定如何分配国际税收管辖权时，应当将涉及经济活动的所有事实都考虑在内。在云计算环境下，这种观点具有正当合理性，为我们弥补国际税收制度中有关云计算服务国际税收管辖权分配规则的空白，概括出能为国际社会借鉴的税收管辖权规则提供了新的思路。如果采纳“整体事实”规则，就意味着接受其所体现的来源规则，也即将消费市场所在地纳入所得来源地的范围。这样，所得来源地的考虑范围既包括服务器所在地和公司所在地，也包括消费市场所在地。然而，为了从根本上解决问题，我们还必须在“整体事实”规则的基础之上，建立一种可以在国际税收制度中普遍适用的税收管辖权分配的新方案。为此，笔者建议放弃传统的常设机构原则，按照各国对云计算服务所作的贡献来平衡分配各国间的所得。[①]具体而言，首先需对“贡献”下一个恰当的定义来确定跨国云计算服务国际税收管辖权的主体，然后再依据这些主体所作的贡献大小确定具体应该分配的税收权益。

5.1 跨国云计算服务营业利润课税权主体的确定

5.1.1 跨国云计算服务营业利润课税权主体的选择原则——“贡献”原则

从各国和 OECD 的国际法律实践来看，如果外国居民享受了一国的公共服务和财产权利的保护，国家就有权向该外国居民征税；而本国居民需就其世界范围内的所得纳税，因为无论本国居民在哪获得的所得，都受到本国法律的保护。这说明，一国为本国居民和外国居民提供有效的法律保护是其享有征税权的依据。而且，“整体事实”规则之所以认为应将消费市场纳入所得的来源地也是因为消费市场所在国为云服务企业提供了保护。因此，一国对云计算服务所作的“贡献”应当主要考虑两个要素：首先，一国能否提供最低程度的保护。[②]其次，一个理性的人是否会在一国不提供法律保护的前提下进行虚拟经营。也就是说，一国对云服务企业所做的贡献除了要看一个国家对企业经营的保护程度（即第一个要素），还要看企业的经营活动在多大程度上依赖该国的法律保护（第二个要素）。如表一所示。因此，当某个企业在该国的经营活动可以不依赖国家的法律保护就能进行时，就不能说该国作出了贡献。显然，对于第一个要素，现代绝大多数国家可以都可以满足。而第二个要素，如果没有量化的指标，很难实际操作。因此，为了明确企业的经营活动对国家法律保护的依赖程度，我们设定：产生所得低于 10 万美元的云计算服务视为不依赖于国家法律保护就可以进行的经营活动，产生所得高于 100 万美元的云计算服务视为必须依赖国家法律保护才能得以正常运行的经营活动，而在这两者之间的部分视一个理性人的角度而定。一般而言，如果一国能够按需提供法律保护，企业因此而愿意在该国进行经营

① 美国税法典就有在各州或地区按生产地和消费地的贡献分配税收管辖权的相关规定.
② 最低程度的保护，是指最弱意义国家理论所提出的国家的功能仅限于保护它所有的公民免遭暴力、偷窃和欺诈.

活动，就可以说一个理性的人依赖于国家的法律保护。反之，则不然。当然，随着云计算在世界经济活动中占据越来越重要的位置，设定的门槛值也会有所变化。各国所作的“贡献”只有符合定义要素才有权向云计算服务征税。

表 一

<table>
<tr><td colspan="4">贡献</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="3">一国能否提供最低程度的保护（国家对企业经营的保护程度）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2</td><td>所得<10 万美元</td><td>不依赖国家的法律保护</td><td rowspan="3">企业经营对国家保护的依赖程度</td></tr>
<tr><td>所得≧10 万，≦100 万美元</td><td>依理性人的角度而定</td></tr>
<tr><td>所得>100 万美元</td><td>必须依赖国家的法律保护</td></tr>
</table>

5.1.2 跨国云计算服务营业利润课税权主体的排除——服务器所在地

在依据各国所作的贡献分配税收权益的方案下，笔者建议云服务器所在地不应参与分配税收权益，而是有权征收一笔固定的费用，这笔费用的多少与云服务产生的所得无关。之所以做出这样的安排有以下几个理由。首先，云计算公司在服务器所在地进行的经营活动微乎其微,承担的风险较少。其次，云计算技术利用多个服务器场执行命令和任务，分散控制。当其中某个服务器场停止运行时，另外的服务器场就会代替其完成任务。因此，在无法明确某个服务器在运行中具体发挥多大作用的情况下，也就无法按照贡献大小分配税收利益。再次，如果赋予服务器所在国向云计算服务征税的权利，云计算公司会将它们的服务器设置在税收条件最佳、风险最小的地方。很明显，考虑到安全因素，许多国家都不是一个理性的公司投资服务器场的理想之地。例如，假如中国没有保护云计算的相关法律，一个美国的跨国云计算公司可能不愿将其服务器设置在中国。同样，也不会愿意在白俄罗斯投资建立服务器场，因为白俄罗斯的政府独裁专制，该国保护云服务器的法律独断专行，云服务器赖以运行的互联网基础设施性能不稳，不可靠。因此，如果让云服务器所在地参与分配所得，会导致大多数欠发达国家不能从中得利，从而造成税收分配不均。由此，笔者认为让云服务器所在国征收固定费用的方案比让其参与分配所得的方案显得更公平合理、更具现实性和可行性。

5.1.3 跨国云计算服务营业利润课税权主体的实例展示

由上文可知，跨国云计算服务营业利润课税权的主体只包括云服务企业所在国和消费市场所在国，从而排除了服务器所在国的税收管辖权。现假设：云服务公司 D 的总部和运营都在荷兰，服务器场在英国，目标客户主要在美国。其他国家，比如索马里、印度也有部分客户。公司总收入每年达 100 万美元，其中，80%来自美国（80 万美元），12%来自索马里（12 万美元），另外 8%来自印度（8 万美元）。如果按照以上所述的“贡献”来分配所得，可以得到如下结论：首先，毫无疑问，云服务公司 D 不仅依赖美国市场的客户，还依赖来自美国的收入。美国提供给 D 公司的也不只是最低程度的保护，因为如果美国客户接受了服务但不愿付款给 D 公司，D 公司起诉客户时美国拥有唯一的诉讼管辖权。而且，

美国提供一整套完整的法律系统来支持 D 公司在美国的虚拟经营。既然美国可以按需给 D 公司提供保护，从一个理性人的角度，D 公司就愿意在美国进行经营活动。同时，作为公司总部和营业地的荷兰也一样。因此，美国和荷兰都能参与分配所得。英国作为云服务器场所在地则有权征收一笔固定的费用。其次，D 公司无需向印度和索马里纳税。因为在印度经营的所得小于门槛值 10 万美元，说明该公司在印度进行的经营活动极少，属于最低程度的经营活动，[①]因而需承担的风险也较小，尽管没有法律保护，一个理性的人也愿意选择在印度经营，即不依赖于该国的法律保护。然而，尽管索马里的经营所得高于门槛值 10 万美元，但没有达到 100 万美元，而且该国政府因太过弱小根本不能提供法律支持来保护云服务公司，也难以采取任何法律行动来制止客户不合法的行为。因此，D 公司在该国提供服务面临着较高的风险，该国的客户也必须支付较高的服务费用。在这样一个缺乏法律保护的国度，一个理性的人是否愿意在该国进行虚拟经营还未可知。当然，由于 D 公司在该国只进行有限的经营，[②]而且大多数理性的人都可能不会选择在没有法律保护的条件下进行经营活动，因此该公司不应就云服务所得纳税似乎更为合理。但如果索马里政府通过不断改善本国的服务来吸引外国投资，一个理性的人因此而愿意到该国从事经营活动，那么云计算公司就可能为此纳税。这样说来，按照贡献分配税收权益的方法还制造了一种激励因素，促使着索马里改善本国提供给外国云计算公司的配套服务。

5.2 跨国云计算服务营业利润课税权主体之间的税收利益分配方案——预扣税与再分配结合的方案

5.2.1 单纯的预扣税方案及其不合理性

在过去的 15 年里，就电子商务的征税而言，国外已有几种可供选择的模式。[③]学者 Avi-Yonah 提出了一种既可针对 B2B 交易，也能适用于 B2C 交易的预扣税方案。其认为，应在消费地按照企业所得税税率就一个企业在产品生产地未被征税的毛所得收税。如果企业在消费地进行了纳税申报，也可按净所得课征。在此之后，学者 Doernberg 又提出征收 10%的预扣税，但学者 Cockfield 则认为 5%较为合适，而且只适用于 B2B 电子商务交易。此外，学者 Reihold 则建议在消费国征收 2%-4%的预扣税。

忽略这些征税模式和税率的细微差别，可以发现他们理论的实质即放弃传统的常设机构概念原则，采用预提税的国际税收权益分配方案，本质上是期望通过一次分配而达到平衡各国税收权益分配之目的。这也是国内大多数学者青睐的方案。[④]从某种程度上说，这些征税模式设计的宗旨在于实现资本输出中性。为了使纳税人在进行投资时不必从税率的高低考虑（通常是从发达国家到发展中国家），最理想的状态就是资本输入国与资本输出

① 营业所得小于 10 万美元.
② 尽管不是最低程度的经营，但也大大小于 100 万美元.
③ Reuven S.Avi-Yonah. International Taxation of Electronic Commerce. 52 TAX L.REV.507(1996); Arthur J. Cockfield. Balancing National Interests in the Taxation of Electronic Commerce Bsiness Profits. 74 TUL.L.REV.133(1999); Richard L. Doernberg. Electronic Commerce and international Tax Sharing. 16TAX NOTES INT'L 1013,1013-22(1998); Richard L.Reinhold. Some Things That Multilateral Tax Treaties Might Usefully Do. 57 TAX L.661(2003).
④ 廖益新. 数字经济环境下跨境服务交易利润国际税收的原则和方案. 国际经济法学刊[J]. 2014(3).

国的税率之和等于资本输出国国内实行的税率。这些征税模式的合理性也在于此。

事实上，云计算服务在实质上与传统电子商务模式下其他无形产品的交易一样，都颠覆了利用常设机构原则来确定营业利润管辖权的规则。但云计算交易的模式又不同于一般性的无形产品。在云计算环境下，如果机械照搬以上学者建议的传统电子商务征税模式，妄想通过一次分配就实现国际税收权益分配的公平合理以及避免全球税基侵蚀和双重不征税现象，是不现实的。

为了证明这种分配方案的缺陷，在此设定一种情形予以说明。假设云服务总所得为100万美元，按照上述学者对传统电子商务的征税模式予以分配，消费地只分配5%的预扣税，生产及研发中心分配95%的预扣税，即在生产地和消费地之间各按95万美元及5万美元分配税收利益。假设云服务公司的生产地或者研发中心位于荷兰，云计算在该国的税率是20%。公司服务器在英国。消费地为美国，税率为30%。服务器所在地英国征收固定的费用，比如1万美元。在这种情形下，荷兰的应税额即为19万美，[①]美国为1.5万美元。[②]显然，由于生产地与消费地之间分配的税收利益相差太大，云服务企业会竞相选择在低税率甚至零税率的国家设立生产及研发中心，大量税收随之流失。“云避税港”的恶性税收竞争会越演越烈。因此，笔者认为，只有初次分配[③]与再次分配[④]相结合的方案才是能够实现平衡国际税收分配之目的、具有现实性和可行性的税收管辖权的最佳方案。

5.2.2 预扣税与再分配相结合的方案之具体内容

从本质上而言，在各国间如何分配税收权益有两种可供选择的方案：第一，平均分配；第二，按照各国对云服务所作的贡献大小来分配。如果云服务商在各国都以类似的方式进行经营活动，第一种方案简便、确定，是首选。然而，实际上云服务商在各国的经营活动并不相同。因此，本文认为应按照第二种方案在各国间分配税收权益，即在云服务企业的生产地和消费地之间按照各自所作的贡献大小分配所得。[⑤]

按照传统上电子商务的征税实践，企业实体的生产中心理应分配大部分的税收利益。同时，考虑到云服务公司的研发中心集中了大批专业技术人员，在云服务运作过程中的贡献较大，因此，公司研发中心应当属于企业生产地的一部分。在按照贡献分配税收权益的模式下，尽管消费地可以参与分配，但也不能因此而减少分配给生产和研发中心的税收利益。因此，笔者认为，消费地按照50%分配税收利益能够实现公平合理。如果有多个消费地，则由多个消费地分割这50%的税收利益。换言之，就是在生产地与消费地之间平均分配税收利益。这样安排能够降低人为地转移利润的机会。一方面，如果让生产研发中心分配过多的税收利益，很容易导致云服务商避税的结果。因此，要避免云服务商选择性地定位生产研发中心，最大限度地降低不同国家税率高低所带来的影响，分配给生产研发中心的利益也不能太多。另一方面，如果消费地分配的税收利益仅为10%，甚至小于10%（上

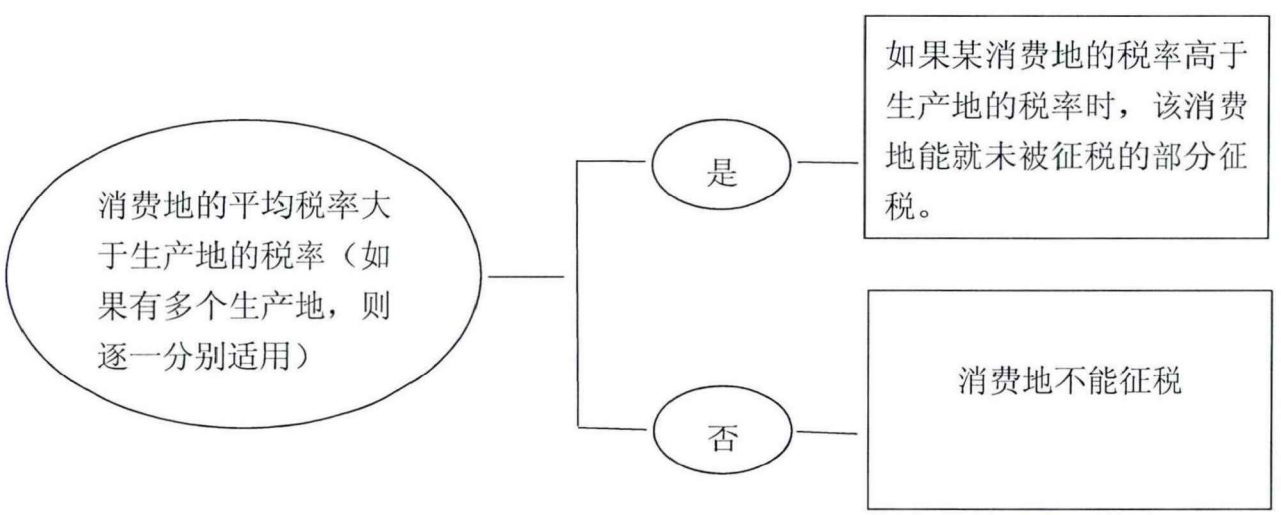
① 95*20%.
② 5*30%.
③ 初次分配即预扣税方案.
④ 再分配是因税率差而分配.
⑤ 生产地包括云服务企业所在地及研发中心，不包括服务器所在地。服务器所在地不参与分配，只征收一笔固定的费用.

述学者对传统电子商务征税的建议），云服务企业就会将生产中心选择在一些低税率甚至零税率的国家，这样做只会加剧“避税天堂”的恶性税收竞争。

在此，假定情形二：在上文提到的第一种情形基础之上改变消费地的预扣税，按照生产地与消费地之间平均分配税收利益的方案，即在生产地和消费地均按50%征收预扣税。因此，荷兰及美国应分配的税收利益均为50万美元。荷兰的应税额为10万美元,[①]美国为15万美元。[②]在这种情形下，生产地荷兰与消费地美国仍有税额差5万美元，[③]虽然不能完全阻止云服务公司有选择性地将生产地及研发中心定位于低税率的国家或地区，但已经最大限度地降低了避税的可能性。

然而，尽管消费地征收50%的预扣税能大大降低人为转移利润的机会，但也不能从根本上解决云服务企业往低税率国家转移生产中心的问题，从而与资本输出中性理论相悖。[④]从这个意义上讲，再分配发挥着至关重要的作用。再分配的目的就是要消除税率高低对企业经营活动的影响。为了达到这个目的，笔者认为只有当生产地的税率低于所有消费地税率的平均值且某一消费地的税率高于生产地的税率时，该消费地才有权参与分配因税率差而未被征税部分的所得，如下图五所示。也可以这么说，即使某一消费地的税率高于生产地的税率，但生产地的税率高于所有消费地税率的平均值时，该消费地也没有征税权。之所以这样处理是因为，在这种情况下，税差相对于全球税率水平来说是微不足道的。

图五



5.2.3 预扣税与再分配相结合的方案之可行性

在此假定第三种情形：与上述第二种情形基本相同，只是在此基础上进行了再分配。再分配按照前述图五所示的方案进行：消费地的平均税率高于生产地，即美国的税率高于

① 50*20%.
② 50*30%.
③ 50*1*30%-50*1*20%.
④ 资本输出中性理论要求投资不受不同国家税率高低的影响.

荷兰；[①]某一消费地的税率高于生产地，也即美国的税率高于荷兰。因此，美国除了按照30%的税率征收15万美元，[②]还要在此基础上征收因税率差产生的5万美元。[③]在此情形中，因在消费地实行50%预扣税的前提下进行了再分配，所有税收激励因素都得以消除。无论云服务企业将生产地建立在哪个国家，纳税义务都不会因为各国之间税率高低有所影响。

一旦理解了其中的原理，就可以将消费地从一国扩大至多国，即第四种情形。在情形四中，云服务公司总所得仍为100万美元，生产地仍位于荷兰，分配50%的税收利益。消费地除了美国，还包括法国、日本和印度。这四国根据自身的消费市场分割剩下50%的税收利益。服务器所在地为英国，征收固定费用一万美元。现假定：（1）云服务商在四国的经营所得分别为60万美元、20万美元、10万美元、10万美元，那么根据该消费市场四国应分配的税收利益比例分别为30%[④]，10%[⑤]，5%[⑥]及5%[⑦]，即30万美元、10万美元、5万美元、5万美元。（2）四国的税率分别为30%、15%、20%、25%，平均税率即为22.5%。如下表二所示。

在情形四中，由于四国的平均税率高于荷兰的税率，因此需要将未被征税的部分分配给消费地税率高于生产地税率的国家。因此，美国和印度还需就税率差征税，而其他消费地，比如法国、日本，由于这两个国家的税率小于或等于生产地的税率，无权征税。首先，美国应按照本国30%的税率征税9万美元，还应根据本国与荷兰之间的税差征收2.5万美元。[⑧]其次，印度也应按本国25%的税率征收1.25万美元，还应根据税差征收1.25万美元（分析同美国）。通过再分配，即使各国税率高低不同，也不会影响到云服务商对生产地的选择。

---

① 消费地只有美国一个.
② 50*30%.
③ 50*1*30%-50*1*20%.
④ 60*50%.
⑤ 20*50%.
⑥ 10*50%.
⑦ 10*50%.
⑧ 因税率差未被征税的收税利益为50万美元，将这部分税收利益在美国与印度之间平均分配，即美国和印度各25万美元，25万美元在美国按照30%的税率应税额为7.5万美元，而这25万美元已在荷兰按照20%的税率征收5万美元，减去这部分已征收的部分即为2.5万美元.

表 二

消除所有激励因素的税收利益分配方案（消费地由一国扩大到多国）							
	荷兰(生产地)	美国	法国	日本	印度	英国	总额
税收利益分配的百分比	50%	30%	10%	5%	5%	固定费用：1万美元	-
税率	20%	30%	15%	20%	25%	-	-
应分配税收利益(万美元)	50	30	10	5	5	-	100
应税额（万美元 ）	10	9	1.5	1	1.25	-	22.75
因税率差产生的税额（万美元）	0	50*0.5*0.3-10*0.5=7.5-5=2.5	0	0	50*0.5*0.25-10*0.5=6.25-5=1.25	-	3.75
应税总额(万美元)	10	9+2.5=11.5	1.5	1	1.25+1.25=2.5	-	26.5+1=27.5

从根本上说，依据贡献分配税收利益的方案因考虑了其他一些经济性质的税收因素，比如考虑了人力资本、消费地、知识、市场大小、法律系统等，它既有利于发达国家，也有利于发展中国家，符合税收制度确定性、简洁性、灵活性的要求，能够有效防止人为地转移云服务活动以及税收的流失。一方面，在这种方案下，发展中国家为了获得向云服务征税的权利，[①]不得不想方设法改善本国政府的服务能力。另一方面，这种方案赋予了作为消费市场的发达国家向云服务征税的权力，因而能够减少人为地税收转移。

总的来看，依据贡献分配国际税收权益的方案说明：传统上我们以实体存在衡量某公司是否利用了一国公共基础设施的做法已经失去了意义。在数字经济，尤其是在云计算环境下，为解决征税的难题，这种方案具有较高的灵活性，而且还与税收中性理论相符。因此，可以作为我们解决跨国云计算服务营业利润课税权分配的参考途径。

① 所得通常在10万-200万美元之间.

结语

从国际税收法律实践来看，在云计算环境下无论是美国还是OECD，都倾向于改编传统上为实物贸易设计的相关税收法律规则，进而适用于虚拟世界的无形交易。然而，这种做法只会产生新的税收漏洞。许多跨国企业已经开始注重挖掘对自身有利且合法的国际税收法规来组织生产经营，而他们唯一的目的就是想法设法进行避税。因此，如果现有的国际税收法律制度无法解决如何应对云计算服务征税的问题，将会加剧税收流失的现状。面对日益复杂的国际税务环境，尽管美国以及其他政府和国际组织就现有的税收法规和协定作了新的调整和规定，但似乎都无法跟上全球经济发展的步伐。而在云计算环境下，随着跨国公司在国际市场贸易中进入壁垒的进一步减少，各国之间的征税界限也会变得越来越模糊不清。

随着经济全球化和信息技术的发展，几个世纪以前形成的国际税收制度变得日益复杂和不确定。这种复杂性和不确定性已经开始造成了税收制度运行混乱的尴尬现状。一些国家甚至很难将自身的征税制度适用于诸如“星巴克咖啡”这样简单的商品，更不用说云计算环境下复杂的多的无形交易。然而，简洁是税收制度的本质要求。正如爱因斯坦的座右铭所诠释的：“如果你不能向一个六岁的孩子解释清楚所要表达的意思，那么，连你自己都没能理解清楚。”为了简化现行的国际税收法律制度，就云计算而言，本文建议按照各国对云计算所作的贡献来分配国际税收权益。事实上，这种分配方式也可以适用于其他数字化服务活动。

当前，各国以及OECD比以往任何时候更需要寻求一种可以灵活适用于网络经营活动，包括云计算的税收管辖权分配制度。当然，让各国都采纳本文建议为云计算服务制定专门的税收权益分配方案是不现实的，因为各国代表的政治利益不同，所做的各项决策根本无法用经济理论逻辑予以解释。尽管如此，笔者仍相信，本文建议的方案能为各国及其它组织在应对云计算服务征税的挑战中提供一些参考，这是十分有必要的，也具有相当积极的现实意义。

具体到我国，云计算作为近年来信息和通信领域发展最迅速的产业之一，给我国的生产生活方式和商业模式带来了强大的冲击和根本性改变，对我国国民经济和社会发展的战略支撑与创新引领作用日益凸显，加快发展云计算产业对加快经济增长、促进产业结构转型升级、支撑城镇化发展、推动与传统产业的融合发展具有重要意义。

据Gartner研究报告分析，全球云计算市场规模从2009年的586亿美元增长至2015年1780亿美元，预计到2019年将达到3150亿美元。[①]其中，2013年云服务的主要市场集中在一些欧美发达国家，[②]美国和西欧的市场份额分别约为全球的50%、23.5%，而中国仅为4%，与欧美及日本等发达国家相比，差距较大。尽管我国云计算服务市场总体规模较小，但增速显著高于全球平均水平，正处于爆发性增长的趋势。据中国工业和信息化电信研究院日前发布的《2016云计算白皮书》显示，我国云计算市场取得了较大的成就。2015年

① 陈阳. 国内外云计算产业发展现状对比分析. 北京邮电大学学报[J]. 2014(16).
② 占全球云服务市场规模的75%以上.

我国云计算整体市场规模突破378亿元，增速达31.7%。虽然我国云计算技术与设备已经具备了一定的发展基础，但由于受到不同的发展环境、国家政策等因素的影响，我国云计算服务市场尚处于起步阶段。然而，中国庞大的人口数量、日益普及的互联网以及不断提升的信息化程度，也给中国云计算市场未来的发展带来了良好的契机，中国成为全球云计算服务主要消费市场指日可待。[①]

尽管我国现阶段也默认以服务器所在地作为云服务所得的来源地，但随着我国云计算服务市场规模不断扩大，中国必将在云计算服务市场中扮演越来越重要的角色，长此以往，税收流失现象也会越来越严重。因此，从长远来看，我国也应当着眼于本文所提出的国际税收管辖权分配方案，为云计算服务制定专门的立法，才能确保我国在国际贸易中正当的税收权益。

① 张静. 中国云计算市场现状及展望. 中国公共安全[J]. 2012(17).

参考文献

一、中文类

[1]张丽芳. 跨国云计算的国际税收问题. 国际税收[J]. 2014(8).

[2]廖益新. 数字经济环境下跨境服务交易利润国际税收的原则和方案. 国际经济法学刊[J]. 2014(3).

[3]崔晓静、赵洲. 数字经济背景下税收常设机构原则的适用问题. 法学[J]. 2016(11).

[4]张亚勤等主编. 云计算 360 度——微软专家纵论产业变革[M]. 北京：电子工业出版社. 2013:63.

[5]王洪良. 跨国电子商务中国际税收管辖权的冲突与对策. 国际经贸探索[J]. 2007(9).

[6]梁学平、李平. 电子商务环境下国际税收利益的分配问题研究. 当代财经[J]. 2003(1).

[7]蔡庆辉. 电子商务环境下国际税收协定所得分类规则适用问题研究. 厦门大学法律评论[J]. 2001(1).

[8]廖益新主编. 国际税法学[M]. 北京：高等教育出版社，2008：65.

[9]廖益新. 数字经济环境下营业利润课税权的分配. 厦门大学学报[J]. 2017(4).

[10]汪珺. 避税港和恶性税收优惠制度识别质疑——浅析 OECD 关于恶性税收竞争的报告. 税务与经济[J]. 2000(5).

[11]刘笑. 诺齐克“最弱意义国家”理论探析. 渭南师范学院学报[J]. 2012(1).

[12]陈阳. 国内外云计算产业发展现状对比分析. 北京邮电大学学报[J]. 2014(16).

[13]张静. 中国云计算市场现状及展望. 中国公共安全[J]. 2012(17).

二、英文类

[1]Reuven S.Avi-Yonah. International Taxation of Electronic Commerce. 52 TAX L.REV.507(1996).

[2]Richard L. Doernberg. Electronic Commerce and international Tax Sharing. 16TAX NOTES INT'L 1013,1013-22(1998).

[3]Arthur J. Cockfield. Balancing National Interests in the Taxation of Electronic Commerce Bsiness Profits. 74 TUL.L.REV.133(1999).

[4]Richard L.Reinhold. Some Things That Multilateral Tax Treaties Might Usefully Do. 57 TAX L.661(2003).

[5]Stephen J.Lusch. State Taxation of Cloud Coputing(2013). http: //heinonline.org.

[6]Gil Savir. A Suggested Framework for the Taxation of Cloud Computing(2015). https: //papers.ssrn.com.

[7]Lawrence Lokken.What is this Thing Called Source?28(2011). http://papers.ssrn.com/abstract=1795256.

[8]James Carr & Jason Hoerner & Shirish Rajurkar & Chanin Changtor.Cloud Computing: U.S. Tax Compliance Complexity for Foreign Subsidiaries(2012).http: //heinonline.org.

[9]Fleming & J.Clifton. Electronic Commerce and the State and Federal Tax Bases. Brigham Young University Law Review (2000).

[10]Avi-Yonah. Globalization and Tax Competition: Implications For Developing Countries. at 4.

[11]Richard A. Musgrave. International Tax and Public Finance: The Role of the State in Fiscal Theory. volume 3. at 248.

致谢

写到致谢时，我心潮澎湃，因为这代表我的研究生生活即将正式画上一个句号。进入湘大读研时我刚好过了而立之年，毫无疑问在同班同学中我的年龄是最大的。大学生活对于我来说已遥远而美好。从2008年迈出校门走向工作岗位而后结婚，先后在浙江的两个药业公司从事了将近六年的外贸工作。不管工作、生活上如何变化，我心里一直坚持着一个继续学习的梦想。2014年决心辞职专门考研，其过程也经历曲折。从报考英语转移到15年的考法硕，最后感激湘大接受我的调剂。湘大成了我的幸运之地。在这完成了我人生中的重要一部分：2016年在老师同学的陪伴下我的宝宝在湘大出生。感谢湘大的宽容以待，给予了我作为母亲体会到的太多庇护。感谢我的导师王霞老师的支持和理解。感谢同学们的帮助和照顾。

在湘大三年的学习生活中，我切身感受到了湘大浓厚的学习氛围，老师们的严谨治学。在本篇论文中王霞导师为我提供了力所能及的一切支持。在修改毕业论文期间，王霞老师赴台湾交流，然却仍然不忘关注论文进展，并及时给予悉心指导，不厌其烦地提供修改意见，从未分毫放松要求。王霞老师扎实深刻的学术底蕴，乐观豁达的处事理念，因材施教的教育方式让我受益匪浅。让我领悟到要用认真扎实的学术心态去面对治学道路上的一切困难，在漫漫法学长路上，导师永远是我的指明灯。

在论文即将画上句号的时候，望着满纸文字，欲言还休。三年的时光就在不知不觉中悄然而逝。初时的梦想，经历的磨练和拥有的快乐最终都在淡然一笑中，成为漫长人生旅途中的一段过往。在这段经历中，对我影响最为深远的便是那些贯穿我学业的师长们和相伴我的同学们。感谢师长们对我的不倦教诲，感谢同学们分享我的苦与乐。特别感谢研究生期间所有的任课老师们。你们渊博的学识，辩证的思维，创新的意识以及严于律己的品格在给我树立成功榜样的同时也成为我将来奋斗的目标。在此，我衷心的祝愿恩师绿水青山春常驻，桃李芬芳满天涯。

在学期间发表的学术论文与研究成果

[1]冯忠芳.美国跨国云服务所得分类规则适用问题初探[J].福建质量管理.2018，39（4）：262-263